

《【문제16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제1심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첩부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1주일 이내에 `항고장`을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음1) 甲이 항고장을 항고법원이 아닌 원심법원에 제출한 것이 적법한 절차인지 검토하고, 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 내리지 않은 경우 항고법원이 취해야 할 심리 방식과 조치에 대하여 논하시오.》

<문제16.2의 물음1> 소장각하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 소장각하명령에 대한 항고장을 원심법원에 제출하였으나 항고이유를 기재하지 않았고, 원심재판장은 별도의 조치 없이 사건기록을 항고법원으로 송부한 상황이다. 쟁점으로 <항고장을 원심법원에 제출한 절차의 적법 여부와 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 하지 않은 경우 항고법원이 어떠한 심리 방식과 조치를 취하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고장의 제출 방식의 적법 여부와 항고법원의 심리 방식 및 조치를 논한다.

II. 항고장의 제출 법원 및 적법성 검토

1. 원칙적인 제출 법원

- "민사소송법 제443조"에 의해 준용되는 제396조 등에 따르면, 항고는 항고장을 원심법원에 제출함으로써 한다. 이는 상소의 일종인 항소나 상고가 원심법원에 제출되어야 하는 것과 궤를 같이한다.

2. 사안의 경우

- 甲은 소장각하명령에 불복하여 항고장을 작성한 후, 항고법원이 아닌 명령을 내린 원심법원에 제출하였다. 이는 법령이 정한 적법한 절차에 따른 것이므로 제출 법원의 관점에서 甲의 항고는 적법하다.

III. 항고이유 기재 여부에 따른 법원의 조치

1. 항고이유 부기 의무의 성격

(1) 일반항고와 즉시항고의 구별

- 민사소송법상 일반적인 항고의 경우 항고장에 항고이유를 반드시 기재해야 하는 것은 아니며, 항고이유서를 제출하지 않았다고 하여 항고가 바로 부적법해지는 것은 아니다. 그러나 즉시항고의 경우 신속한 결정을 위해 항고이유를 적도록 권장된다.

(2) 소장각하명령에 대한 즉시항고

- 소장각하명령에 대한 불복은 즉시항고(제254조 제4항)에 해당한다. 다만, 항소와 달리 항고 절차에서는 항고이유서를 기간 내에 제출하지 않았다고 하여 항고를 각하한다는 명시적인 규정이 없으므로, 이유 기재가 없다는 사실만으로 곧바로 각하할 수는 없다.

2. 원심재판장의 조치

(1) 항고장 심사권

- 원심재판장은 항고장이 접수되면 형식적 요건을 심사한다. 항고기간의 도과나 인지의 미첩부 등 명백한 부적법 사유가 있다면 보정을 명하거나 각하해야 한다.

(2) 이유 미기재 시의 대응

- 항고이유가 기재되지 않은 것은 항고장의 필수적 기재사항 위반이 아니므로, 원심재판장이 이를 이유로 보정명령을 내리거나 각하할 수는 없다. 따라서 원심재판장이 사건 기록을 항고법원으로 보낸 조치는 적절하다.

3. 항고법원의 조치

(1) 심리 방식

- 항고법원은 기록을 송부받은 후 항고이유가 기재되어 있지 않다면, 항고인에게 항고의 구체적인 이유를 밝히도록 독려하거나 서면 제출을 명하는 심리 절차를 진행해야 한다.

(2) 항고이유의 소명 및 판단

- 항고인이 끝내 이유를 밝히지 않거나 제출된 이유가 이유 없다고 판단되면 항고기각 결정을 내린다. 반대로 원심의 소장각하명령이 부당하다는 점(예 : 이미 인지를 첩부했음에도 착오로 명령이 내려진 경우 등)이 밝혀지면 원심명령을 취소한다.

IV. 사안의 적용

1. 항고장 제출의 적법성

- 甲이 원심법원에 항고장을 제출한 것은 "민사소송법 제443조" 및 "제396조"의 취지에 부합하는 적법한 절차이다.

2. 법원의 후속 조치

- 원심재판장이 항고이유 미기재를 이유로 각하하지 않고 기록을 송부한 것은 타당하다. 항고법원은 甲에게 항고이유를 소명할 기회를 부여해야 하며, 甲이 소장각하명령의 원인이 된 인지 미첩부 사유를 해소했거나 명령의 부당함을 소명한다면 항고법원은 원심명령을 취소하고 사건을 다시 진행하도록 해야 한다.

V. 결론

- 甲의 항고장 제출은 적법한 법원에 이루어졌다. 항고이유의 기재는 항소와 달리 강제되는 요건이 아니므로, 항고법원은 즉시 각하할 것이 아니라 심리 절차를 통해 항고인에게 이유 소명 기회를 부여한 후 항고의 당부를 판단해야 한다.